

1500376-83.2021.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... réu disse que todo o dinheiro era proveniente do tráfico. Informou que achou também folhas com anotações do tráfico de drogas e balança de precisão. Contou que a namorada negou saber da droga na casa. Negou ter abordado esse jovem antes. Comentou que segundo o réu ele fazia esse tráfico há um mês. Afirmou que o réu disse que estes R\$ 50, que ele tinha no colo, havia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Assis - SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500376-83.2021.8.26.0580 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500376-83.2021.8.26.0580

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DA SILVA KILL DO PRADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Gabriel da Silva Kill do Prado, qualificado nos autos, por ter, em tese, praticado o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, c.c art. 61, II, j, do Código Penal e o art. 40, III, da Lei de Drogas. Narrou que no dia 16 de outubro de 2021, por volta da 00h10min., na Rua José Paes Maldonado, Jardim Três Américas, e na Rua Borba Gata, 130, ambos em Assis, Gabriel trazia consigo, para fins de tráfico 41,49 g de cocaína sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo apurado, o acusado mantinha em sua residência cocaína embalada e trazia consigo porções da droga enquanto transitava pela rua com seu veículo Fiat/Palio; policiais militares em patrulhamento no bairro Colinas, próximo à EMEIF Prof João Luiz Galvão Ribeiro, visualizaram o veículo conduzido pelo denunciado emparelhado com um GV/Vectra, cor branca; ao perceber a aproximação da

viatura, Gabriel tentou evadir-se e chamou a atenção dos agentes; Gabriel estava com notas de dinheiro no colo e assumiu que carregava entorpecentes no veículo, mas que sua companheira Júlia não tinha conhecimento dos fatos; Gabriel apontou uma mochila que se encontrava em seus pés, a qual continha 16 porções de cocaína e R\$ 220,00; na casa do acusado, com a autorização dele, encontraram mais 10 porções de cocaína, idênticas às achadas dentro da mochila em seu veículo, além de R\$ 671,00, uma balança de precisão e duas folhas de caderno contendo contabilidade da droga; a forma de acondicionamento, a quantia de droga apreendida, o dinheiro em espécie e as demais circunstâncias da prisão demonstram a finalidade de narcotráfico. Notificado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 156/157).

A denúncia foi recebida em 14/12/2021 (fl. 169).

Em cumprimento à decisão liminar proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça (fls. 183/188), o réu foi posto em liberdade (fls. 196/199).

Foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (fls.161/163 e 215/216).

O douto membro do Ministério Público apresentou alegações finais, nas quais pediu a condenação do réu. Aduziu que: os policiais afirmaram que viram o carro do réu emparelhado com outro, ele tentou fugir e ao ser abordado viram notas de dinheiro no colo dele; acharam 16 porções de cocaína no carro e em sua casa outras 10 porções da mesma droga, além de dinheiro balança de precisão e papéis com anotações sobre a contabilidade da droga; a versão de que a droga apreendida em seu poder e na sua residência era para seu consumo pessoal e de seus amigos restou isolada; os relatos dos policiais foram uníssonos e não há prova de que mentiram; o laudo da perícia no celular do réu constatou diversas conversas relacionadas tráfico de drogas, sobretudo com os contatos "Leandrinho", "Zelão", "Pajé", "Gustavo Oliveira" e "+55 18 99644- 5719", com relatório em arquivo em PDF contendo as transcrições das conversas no link de fls. 226. Pediu a majoração da pena pela elevada quantidade de droga apreendida; a agravante de crime perpetrado durante o estado de calamidade pública; a não aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da apreensão em sua residência de elevada quantia em dinheiro, balança de precisão e anotações relativas à contabilidade da droga (fls.115/116), a demonstrar que Gabriel se dedica ao tráfico; o regime inicial deve ser o fechado, sem benesses legais (fls.239/248).

A douda Defesa pleiteou a absolvição do réu. Sustentou que: a droga encontrada com o réu se destinava ao uso próprio, não há prova de que se destinava ao consumo de terceiros ou de que ele era conhecido como traficante; os policiais não reconheceram o acusado e abordaram-no acidentalmente apenas por um defeito na lanterna do veículo; o acusado não foi visto em situação de mercancia; não há prova de que o réu estava praticando de tráfico de drogas ou que foi visto nessa situação; as drogas foram encontradas em seu lava-rápido; no momento da abordagem nada de ilícito foi encontrado em seu poder; as testemunhas afirmaram que Gabriel era usuário de cocaína; cabe a desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, pela quantidade e a natureza da droga, a narrativa dos policiais de que a abordagem foi acidental e sequer era conhecido nos meios policiais; subsidiariamente, requereu a atenuante da confissão, a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, a fixação de regime aberto, a substituição da pena corporal e restituição do numerário e celular apreendidos (fls. 254/258).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação penal é procedente.

A materialidade do tráfico de drogas ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls. 15/18), auto de exibição e apreensão (fls.19/20), laudo de constatação (fls. 24/26), laudo relativo à balança de precisão (fls.111/112), exame toxicológico (fl.114) e manuscrito (fls.115/116).

Extrai-se do laudo pericial que foi periciado objeto sólido de cor bege, com resultado positivo para cocaína, considerada substância entorpecente. A autoria também é certa e atribuída ao acusado, conforme prova oral colhida sob o crivo do

contraditório.

Em seu interrogatório, Gabriel afirmou que trabalha na padaria do Nobu como auxiliar de padeiro. Relatou que guardava a droga para uso próprio e de colegas. Mencionou desconhecer as anotações encontradas na sua casa. Declarou que usava a balança de precisão para verificar se não estava sendo enganado porque comprava muito e foi enganado umas três a quatro vezes. Salientou que usava entorpecentes somente nos finais de semana e costumava comprar drogas nas sextas. Admitiu ter esboçado fuga com o veículo. Narrou que uma parte do dinheiro apreendido estava no bolso e um pouco no seu colo, pois após receber os valores do condutor do veículo GM/Vectra ficou nervoso ao ver a viatura. Confessou que combinou entregar as 16 porções de cocaína que estavam no carro ao condutor do Vectra e receberia R\$ 800,00 que seriam repassados ao traficante que forneceu a droga. Falou que tal indivíduo havia lhe dado R\$ 600,00 na sua casa, mas não estava com as porções, então combinou de entrega-las perto do bairro Colinas, perto da escola, e ele lhe daria os R\$ 200 restantes. Afirmou que apavorou ao ver os policiais, saiu normalmente, mas foi abordado. Relatou que combinou a transação de droga pelo celular. Mencionou ter comprado 20 porções e recebido 6 de brinde, pagou R\$ 1.300,00 por essa droga. Declarou que fizeram uma "vaquinha" em dois grupos para usarem drogas numa festa juntos, mas não pode dizer quem participaria da festa. Negou ter passagens pela polícia. Mencionou que havia emprestado o carro de sua tia para ir comer um lanche com sua mulher, a sua tia não sabia que ele transportaria droga no carro.

A testemunha Victor afirmou que patrulhava pelo bairro Colinas quando viu um Vectra claro e um Fiat Palio preto parados paralelamente. Relatou que com a aproximação da viatura esse último se evadiu, fato que lhes chamou a atenção. Mencionou que Gabriel estava na condução, abaixou o vidro e notou notas de dinheiro no colo dele. Declarou que ao pedir ao acusado que descesse ele confessou ter droga no carro e que a amásia não sabia dos entorpecentes. Salientou que ele indicou uma pochete em seu pé, onde encontraram 16 porções de cocaína. Disse que Gabriel admitiu ter mais droga em sua residência e lá encontraram mais 10 porções da mesma substância e R\$ 671,00 em espécie, no carro já havia sido apreendido R\$ 220. Acrescentou que ainda na casa encontraram uma balança de precisão e duas folhas com anotações referentes à venda de drogas. Informou que já conhecia o réu porque uma vez apreendeu uma moto dele. Frisou que o local da abordagem é conhecido ponto de venda de drogas. Negou ter perseguido o Vectra porque foi o veículo do Gabriel que chamou a atenção. Negou ter informações de que Gabriel seria traficante.

A informante Julia afirmou que ela e o amásio participariam de uma festa na Chácara Lourenço. Relatou que Gabriel participou de "vaquinha" com amigos para adquirirem drogas para usarem na festa. Mencionou que todo o dinheiro foi dado ao seu companheiro, para que ele adquirisse a droga. Declarou ter ciência de que ele era usuário, mas não é próxima desses amigos e não sabe os nomes. Confirmou que a droga estava com Gabriel e que havia dinheiro no veículo. Narrou que a balança de precisão foi encontrada na casa onde eles residiam juntos, mas nunca a tinha visto nem os papeis com anotações. Negou saber da existência de droga no carro. Informou que Gabriel era auxiliar de padeiro e estavam juntos há dez meses. Disse que o carro era da tia de Gabriel, a qual havia emprestado para utilizarem no final de semana. Negou conhecer o dono do Vectra, sabe que se chama João. Informou que João passou dinheiro ao Gabriel, mas este não passou nada àquele. Negou ter ouvido o que Gabriel falou sobre a droga. Frisou que Gabriel autorizou o ingresso na casa deles. A testemunha Debora negou saber dos fatos. Afirmou que o acusado trabalhava com ela na padaria do Nobu, como auxiliar de padeiro e era registrado. Relatou que ele chegava às seis e pouco, ficava até meio dia, voltava 15:30h e trabalhava até 18h, folgava aos sábados e ia no domingo às 17h para fazer pão. Mencionou que Gabriel é boa pessoa, responsável, nunca atrasou, trabalha certinho, não foi demitido por causa desses fatos.

A testemunha Paulo Negrini afirmou que depois da meia-noite avistou dois veículos parados na via pública, assim que chegou ao lado do Vectra o Palio saiu em disparada. Relatou que o motorista disse estar pedindo informação e decidiram abordar o Pálio. Mencionou que menos de uma quadra o motorista parou, abriu o vidro e viram notas de dinheiro no colo do motorista, que estava com a namorada. Declarou

que na hora que ele desembarcou falou que tinha drogas no carro, estava traficando e a namorada não sabia. Salientou que achou nos pés do assoalho uma bolsa com 16 porções de cocaína embaladas no plástico e R\$ 220, sendo R\$ 50 no colo e o restante nessa bolsa. Ressaltou que o réu disse ter mais drogas e dinheiro na casa, lá apreendeu 671 reais e dez porções de cocaína. Frisou que o réu disse que todo o dinheiro era proveniente do tráfico. Informou que achou também folhas com anotações do tráfico de drogas e balança de precisão. Contou que a namorada negou saber da droga na casa. Negou ter abordado esse jovem antes. Comentou que segundo o réu ele fazia esse tráfico há um mês. Afirmou que o réu disse que estes R\$ 50, que ele tinha no colo, havia recebido do Vectra, mas não conseguiu entregar cocaína ao usuário.

Pois bem. Ressalto que o tráfico de entorpecentes se configura com a prática de várias condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, como tipo misto alternativo que é, a incidência em qualquer delas justifica a violação do bem jurídico protegido. Desnecessário, portanto, o flagrante do momento da efetiva tradição ou venda do entorpecente para incidência do tipo penal. É dizer, as condutas periféricas à efetiva comercialização, como trazer consigo, guardar, transportar ou manter em depósito, por exemplo, são suficientes à transgressão do ilícito penal.

Segundo o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, a classificação da conduta em porte para uso próprio (ou tráfico de drogas, a contrário sensu) se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Os fatos contidos na denúncia foram comprovados pela prova oral. Os policiais militares narraram que avistaram dois veículos parados, um ao lado do outro, ao perceber a viatura o réu empreendeu fuga em um dos automóveis. Os policiais fizeram contato visual e perceberam que o motorista Gabriel tinha notas de dinheiro no colo. Falaram que assim que parou o réu já admitiu ter drogas no carro e eles encontraram no assoalho do condutor 16 porções de cocaína e R\$ 220 em espécie. Acrescentaram que Gabriel admitiu possuir mais drogas em sua residência e lá apreenderam outras 10 porções de cocaína, idênticas às encontradas no carro, R\$ 671,00, uma balança de precisão e duas folhas de caderno contendo contabilidade do tráfico.

É fato que os policiais avistaram o réu numa situação típica de venda de drogas. Estava num ponto conhecido pela traficância, parado ao lado de outro veículo e ao ver a viatura adotou a conduta incriminadora de fugir. Fossem as drogas apenas para consumo próprio não havia motivo para isso, pois todos sabem que a legislação penal é extremamente benéfica com a figura do usuário.

Ainda que os policiais não tenham visto o gesto de troca de objetos, o próprio réu admitiu no interrogatório que combinou entregar as 16 porções de cocaína ao condutor do Vectra e que repassaria o dinheiro ao traficante que forneceu a droga. Frisou que tal indivíduo havia lhe dado R\$ 600,00 na sua casa, combinou de entregar as porções no bairro Colinas, perto da escola, e ele lhe daria os R\$ 200 restantes. A informante Júlia confirmou que João passou dinheiro ao réu.

O fato de policiais terem apreendido no carro o dinheiro esparramado sobre o colo de Gabriel, além das 16 porções de cocaína já embaladas em porções individuais prontas para a venda, corrobora a confissão do requerido em seu interrogatório judicial.

Não bastasse isso, em sua residência ainda foram encontradas outras 10 porções de cocaína iguais às encontradas no carro, totalizando mais de 40g, quantia elevada para alguém que se diz mero usuário. Também apreenderam relevante quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada, e balança de precisão, petrecho tipicamente usado por traficantes para pesar as drogas que embalam. Não convence a versão dita no interrogatório, segundo a qual usa para conferir o que compra, pois certamente nenhum traficante aceitaria o pedido de reembolso do usuário.

Destaca-se a apreensão na casa do réu de papéis com anotações alusivas ao tráfico de drogas, apresentados por fotografias às fls. 115/116, nos quais há nomes, pesos e valores, os quais não foram esclarecidos pelo réu em Juízo. No documento de fl.

115, há anotação em primeira pessoa "Comprei Solofone 5\$", certamente se referindo a papel celofane usado para embalar as drogas. No documento de fl. 116, há menção a "maconha", seguida de nomes, pesos e valores, o que indica que o réu comercializou esse tipo de entorpecente. Aliás, no laudo de fl.111 constou que os Peritos encontraram na balança resquícios de substância seca de cor esverdeada. Outro indicativo claro de dedicação ao tráfico de drogas consiste nas conversas extraídas do celular do acusado. Na conversa datada de 08/10/2021 "Pajé" indaga se o réu "tá tenho"? (sic) e ele responde que não (fl.339). Já no diálogo com "Zelão", em 06/10/2021, ele questiona "E a entreguinha faz pra mim" (sic) e Gabriel responde: "Intão viado to na escola. E to sem maconha mano so nas 25g cuzao" (sic - fls.513/514). Na mensagem trocada com "Clebinho" em 28/09/2021 o réu perguntou "vai querer as 15g intao" (sic), o interlocutor falou "pd pa" (sic), Gabriel disse "tenho q ir em cs pega ainda" (sic), Clebinho indaga se vai demorar e o réu diz que não (fl.521).

O requerido alegou também em seu interrogatório que guardava drogas para uso pelos seus colegas. Sua amásia contou que Gabriel e os amigos fizeram uma vaquinha para o réu adquirir entorpecentes para todos usarem juntos numa festa. É evidente que tal prática também caracteriza o crime, em razão da entrega de drogas ao consumo de terceiros. Sequer o réu e a esposa citaram o nome destas pessoas nem a Defesa trouxe prova segura de que esse rateio existiu, que eram pessoas de convivência do acusado e a finalidade era mesmo o consumo conjunto.

Com a devida vênia ao douto Defensor, as evidências de que existiram atos ilícitos de entrega a consumo de terceiros não podem ceder lugar para a posse de entorpecente para uso próprio. O réu pode até ser usuário de drogas, mas deve prevalecer, para fins penais, no caso em tela, a conduta descrita no tipo que define o crime de tráfico, mais gravosa perante a sociedade, por não ter sido provado que aquelas drogas eram destinadas exclusivamente ao uso próprio.

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicar o princípio in dubio pro reo e nem desclassificar a conduta para posse de drogas para uso próprio.

Outrossim, ele não conseguiu comprovar a origem lícita do dinheiro que foi encontrado em sua posse, apreendido no contexto da traficância. Assim, deve ser decretado o seu perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, II, do CP c.c art. 63 da Lei n.º 11.343/06.

Incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, se o agente realiza o crime nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos.

A jurisprudência das Cortes Superiores é tranquila no sentido de que esta causa de aumento de pena é objetiva, de modo que basta o tráfico nas imediações destes locais, sendo irrelevante que o agente visar ou não os frequentadores. Nesse sentido, cite-se os julgados:

Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional. Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 se justifica

quando constatada a comercialização de drogas nas imediações de estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não os frequentadores daquele local. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 138944, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j.21/03/2017, publ. 03/08/2017).

“a comercialização de drogas nas dependências ou nas imediações [de estabelecimentos prisionais], por si só, já justifica a incidência da causa especial de aumento de pena, sejam quais forem as condições subjetivas do agente que a comete” (HC nº 114.701/MG, 2ª Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13).

“O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local” (HC nº 116.929/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/11/13).

“o espírito, ao que transparece, foi o de punir com maior rigor aquele que, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas, aqui incluídos quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não apenas o comércio, justamente porque em locais como tais, mais fácil é ao traficante passar despercebido à fiscalização, sendo maior, consequentemente, a reprovabilidade de sua conduta” (AgRg no REsp 1346137/SC, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza De Assis Moura, j. em 10.06.2014).

CRIME COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLAS E IGREJAS. CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI 11.343/2006. MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O TRÁFICO ERA PRATICADO NAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES OU QUE OS ENTORPECENTES SE DESTINAVAM AOS SEUS FREQUENTADORES. 1. A jurisprudência deste sodalício firmou-se no sentido de que a causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação do tráfico nas entidades nela mencionadas, ou mesmo que o comércio proscrito destina-se a atingir os seus frequentadores, bastando que o crime tenha sido cometido em locais próximos a tais estabelecimentos, o que afasta a coação ilegal suscitada na impetração.(...) (STJ, HC nº 443828/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 20.06.2018).

No caso dos autos ficou demonstrado que o requerido realizou a traficância nas imediações da escola Prof João Luiz Galvão Ribeiro, o que basta para a caracterização desta causa de aumento, sendo de todo irrelevante que a escola não estivesse aberta naquele momento.

Respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, passo a dosagem das penas, eis que não milita em favor do acusado qualquer dirimente: A culpabilidade do réu, entendida como índice de reprovabilidade da conduta, é normal para a espécie. A quantidade de droga traficada será considerada pelo Juízo quando da terceira fase da dosimetria para quantificar a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. É primário e não ostenta maus antecedentes (fls. 32/33). Inexistem indicativos seguros quanto à conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo penal. As consequências do crime são normais.

Na primeira fase, considerando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase reconheço a agravante do art. 61, II, j, do Código Penal, eis que o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia de Coronavírus. Reconhecidamente, a sociedade encontra-se vulnerável no âmbito da saúde e, também, no aspecto psicossocial, pois o isolamento e as restrições impostas à circulação de pessoas têm causado conflitos psicológicos que levam, muitas vezes, à utilização de produtos químicos, incluindo entorpecentes. Também há notícias de que policiais tem ficado doentes por causa do Coronavírus, de modo que

não é absurdo concluir que essa pandemia pode afetar a fiscalização de crimes como o tráfico. Esta agravante já foi aplicada em no julgamento de um traficante pelo C. STJ: (...) Impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61-II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda a população do Município, colocando em risco a saúde pública (STJ, HC 584871/SP, Min, Nefi Cordeiro, j. em 04.06.2020, destaquei). Além disso, como bem destacou o Exmo. Des. Edison Brandão, "se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (TJSP, Apelação n.º 1509419-67.2020.8.26.0228, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 26.01.2021).

Por outro lado, vislumbro a atenuante da confissão espontânea do crime perante a Autoridade Judicial e da menoridade relativa, eis que Gabriel tinha menos de 21 anos de idade quando dos fatos. Assim, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), porém mantenho a pena no mínimo legal em atenção à Súmula nº 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase presente causa de aumento de pena porque a infração foi cometida nas imediações de estabelecimento de ensino, conforme confirmado pelas testemunhas e constou na fundamentação supra. Aumento a pena em 1/6 (um sexto), atingindo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Deve ser aplicada a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante da ausência de maus antecedentes e de indícios de que se dedique a atividades criminosas e integre organização ilícita. Não vejo inconstitucionalidade neste dispositivo, pois o legislador quis tratar de maneira menos rigorosa o traficante ocasional; houve exasperação da pena para o tráfico em comparação com a antiga Lei nº 6.368/76, de modo que não se justificava um tratamento igualitário entre o traficante profissional e o eventual. Está aí a razão da causa de diminuição em apreço, apta a realizar (e não a maltratar) o princípio da isonomia. O teste de constitucionalidade, à luz do princípio da isonomia, deve ser feito no âmbito do microssistema da Lei de Drogas, não se podendo fazer comparações com outros crimes previstos na legislação.

Para a definição do total de diminuição da pena deve ser levando em conta a quantidade de droga apreendida e a potencialidade lesiva da mesma. Este é o posicionamento da jurisprudência majoritária e foi respaldado em julgado da 1ª Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF, HC 104195, 1ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, j.26/04/2011). Levando em conta a quantidade e espécie de droga traficada (41g de cocaína) e a intensidade do crime, demonstrada pelas mensagens contidas no aparelho celular e pelo fato de ter balança de precisão e anotações do tráfico, diminuo a pena em 1/4 (um quarto) e a torno definitiva em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, cada qual no mínimo legal, em face da renda apurada no interrogatório e do salário mínimo vigente na época dos fatos, valor que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, de acordo com o art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, ambos do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, ex vi da quantia de droga traficada, da intensidade da traficância e de vender drogas numa escola, o que indica maior gravidade da conduta, do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e da regra constitucional prevista no art. 5º, inc. XLIII da Constituição Federal, e de uma política criminal mais rigorosa de repressão aos crimes de tráfico.

Justifico a fixação do regime prisional mais gravoso, a não substituição por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena também pelo fato de estarem ausentes os requisitos dos arts. 44, III, e 77, II, do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja porque o art. 5º, XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inc. LI, da Carta Magna.

Frise-se que a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as hipóteses excludentes do regime de substituição de penas, contempladas no art. 44 do Código Penal, tem como suporte unicamente o critério do legislador ordinário; já a inconversibilidade das penas quando a condenação decorre do tráfico ilícito de entorpecentes têm por si a vontade do constituinte, que em dois momentos destacou a importância da repressão a esse crime, no art. 5º, XLIII e LI, da CF (Arguição de Inconstitucionalidade/HC 120.353, Corte Especial, Rel. Orig. Min. Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler, DJe: 18.12.09)

O crime de tráfico de entorpecentes, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem. Nesse aspecto, acerca da necessidade do regime mais grave para o tráfico de drogas, cito o voto do eminente Desembargador Machado de Andrade, no julgamento da Apelação nº 0004588-12.2016.8.26.0189, julgado em 21/09/2017:

Esse desgraçado vício da cocaína chegou em nosso país e, principalmente, nessa cidade de São Paulo, onde todo mundo sabe que existem logradouros públicos, que foram praticamente tomados por viciados. É bom lembrar que o usuário de cocaína quando não tem dinheiro para adquirir a cocaína pura, que é em forma de pó, passa a se utilizar de uma forma inventada nos Estados Unidos, mais, precisamente na cidade de Nova York, no início dos anos 1970, denominada crack, aliás muito mais potente no sentido de fazer com que apenas com uma aspiração da fumaça tóxica (coloca-se a pedra em um pequeno cachimbo, conhecido como "marica", geralmente de vidro, esquentando-se embaixo com uma chama de isqueiro ou fósforo, e a pessoa suga a fumaça que desprende da pedra de "crack") já se torna dependente desta desgraça que foi inventada por indivíduos alheios a qualquer sentimento de piedade e que tinham somente interesse em ganhar dinheiro. Ora, uma pessoa que transforma seu semelhante num morto vivo, ou seja, um verdadeiro zumbi, como os que se vê na mídia, principalmente televisiva, indivíduos convivendo juntos na maior sujeira e promiscuidade, sendo que os locais onde essas pobres almas habitam, tem que ser constantemente lavado, com jatos de água e detergentes, pela Prefeitura Municipal, a fim de remover o fedor que exala do chão devido às secreções e excrementos que essas pessoas deixam naqueles locais. Tudo o que disse acima, e que é do conhecimento de todos, acontece por apenas uma razão, devido à ação de pessoas destituídas de qualquer sentimento de amor ao próximo, como é o caso do traficante e, nesses autos, do acusado. Com relação à conduta social do recorrente, não há qualquer dúvida que, com sua atividade de traficantes, ele causou um mal irreparável à sociedade, uma vez que muitos adolescentes, provavelmente, foram por ele jogados no inferno de uma vida de usuário de drogas. O direito, como é cediço, é uma ciência mutável, ou seja, ele tem que acompanhar a evolução humana, e se adaptar às suas necessidades que mudam a cada época do desenvolvimento da sociedade. Assim sendo, como uma das finalidades da pena é intimidar um possível criminoso, é mais do que óbvio que um crime como o tráfico de drogas, que, sem falar nos males causados à pessoa humana, abre as portas para inúmeros outros delitos, como furtos, roubos, homicídios, prostituição etc.; não pode receber um tratamento menos gravoso do que um delito de menor potencial ofensivo. Assim, ante o terrível mal que o réu causava à sociedade antes de ser preso não há outro regime, senão o inicial fechado, como forma de contraprestação do Estado à sua conduta. Fixar-se um regime mais benéfico do que o inicial fechado, seria conceder-se uma benesse ao réu, a qual ele não é merecedor.



No mais, a concessão dos citados benefícios, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (art. 59 do Código Penal), gerando ofensa ao disposto no art. 44, inc. III, do CP, e verdadeira sensação de impunidade a esta cidade.

Por fim, foi publicada a Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal. Esta possui previsão legal no art. 42 do Código Penal, segundo o qual "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior".

Pelo art. 1º: "a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, nos termos desta lei". Já o art. 2º traz o § 2º ao art. 387 do CPP: "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade".

Reputo a lei constitucional, por representar a vontade legítima do legislador de diminuir o tempo de espera para a progressão do regime e por competir ao legislador a tarefa de determinar o momento e juízo competente para efetuar a detração. Neste caso concreto, o réu não faz jus à progressão de regime, pois não cumpriu nem 1/6 da pena. Assim, apesar da detração ora realizada, o regime inicial de cumprimento da pena restante ainda será o fechado.

Diante do exposto, com fundamento no art. 387, do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta ação penal para: a) CONDENAR o réu Gabriel da Silva Kill do Prado, qualificado nos autos, à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, cada qual no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, e § 4º, c.c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/06; b) CONDENAR o réu ao pagamento das custas judiciais, previstas no art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita porque se trata de réu pobre; c) DECLARAR a perda, em favor da União, do numerário apreendido nestes autos, com base nos arts. 91, inc. II, do Código Penal, e 63, da Lei nº 11.343/06.

Concede-se ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que por decisão liminar proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 183/188) foi colocado em liberdade provisória e não surgiu fato novo apto a justificar sua prisão.

Conforme art. 61 e § 1º, da Lei de Drogas, o Juiz deve determinar a alienação de maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes previstos na Lei nº 11.343/06. Tal alienação deve ser feita independentemente do trânsito em julgado e no caso de absolvição o valor do depósito será devolvido (art. 62-A, § 2º).

Determino a instauração de incidente para fins de alienação judicial eletrônica do celular apreendido. Autue-se o incidente em apartado e nele tornem conclusos.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Decorrido o trânsito em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2)

Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) confirmada a condenação e a não substituição da pena, expeça-se mandado de prisão com o regime fixado na sentença/acórdão; 4) Extraíam-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 5) Expeça-se ofício ao Banco do Brasil solicitando que efetue a transferência do valor em favor do FUNAD, constando como CNPJ do favorecido o nº 02.645.310/0001-99, banco 001, agência 1607-1, c/c 170500-8, código

identificador nº 2002460000120201, e o envio de comprovante nos autos, no prazo de 10 dias; 6) Expeça-se ofício à SENAD, encaminhando cópia do auto de apreensão de bens, sentença de perdimento, certidão do trânsito em julgado e comprovante do depósito, para ciência. Envie-se-o pelo e-mail cdc.funad@mj.gov.br; 7) Requisite-se a destruição da balança de precisão; 8) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 9) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 10) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 11) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribua ao processo a situação "suspensão", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 12) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 14) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 15) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva".

Assis, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA